

1503242-39.2021.8.26.0071

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cláudio Augusto Saad Abujamra

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/03/2022

... quando interrogado em juízo, negou a prática do tráfico.

A negativa, no entanto, soa como forma natural de afastar a responsabilidade criminal e suas consequências, e não pode ser admitida, porque em contradição com a lógica e com a prova produzida.

Isto porque o crime de tráfico foi comprovado pelo depoimentos de dois agentes de segurança penitenciários, que flagraram ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

3ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-900

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1503242-39.2021.8.26.0071 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503242-39.2021.8.26.0071

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2033927/2021 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 10976260 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-

DEINTER 4, 14700/20/404 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 2033927 -

2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS ADRIANO TAUHYL MACHADO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cláudio Augusto Saad Abujamra

Vistos.

MATHEUS ADRIANO TAUHYL MACHADO foi dado como incurso nas penas do art. 33, caput, combinado com art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006, porque, no dia 06 de dezembro de 2020, por volta das 07h10, nas dependências do Centro de Progressão Penitenciária I de Bauru, nesta cidade, trazia consigo, para fins de tráfico, dois segmentos de papel contendo 0,016 gramas de substância MDMB-4en-PINACA, droga que determina dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Notificado (fls. 115), o réu apresentou a defesa preliminar de fls. 120/121.

A denúncia foi recebida por despacho datado de 01 de agosto de 2021 (fls.

127/129).

Em audiência, foram ouvidas testemunhas e o réu foi interrogado (fls. 155 - audiovisual).

Em alegações finais, o representante do Ministério Público pediu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia (fls. 158/161).

Já a defesa técnica se manifestou a fls. 166/172, alegando que: 1)- as provas são frágeis; 2)- os depoimentos dos agentes penitenciários não são suficientes para a condenação; 3)- eventualmente, a conduta deve ser desclassificada para a prevista no artigo 28 da Lei Antidrogas, pois as testemunhas não trouxeram elementos a evidenciar que a droga seria destinada a terceiro, o réu não tinha em seus pertences pessoais produtos comumente usados por presos como moeda de troca na aquisição de entorpecente ou cigarros, a quantidade de droga não era exagerada. Pediu a absolvição e, alternativamente, a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/06 e a fixação do regime inicial diverso do fechado.

É o relatório. Passo a decidir.

A materialidade do crime está demonstrada pelo auto de apreensão de fls. 09 e pelo laudo pericial de fls. 15/17 (dois segmentos de papel de cor amarela com peso bruto de 5,48 gramas e contendo 0,016 gramas de substância MDMA-4en-PINACA).

A autoria e o intuito de traficância derivam da prova oral e das circunstâncias do caso e devem ser atribuídos ao acusado.

Em juízo, a testemunha Jefferson Colmati Santos Silvagni, agente de segurança penitenciária, afirmou que, logo após a entrega do café da manhã aos detentos dos raios 2 e 3 da unidade, os presos do raio 3 reclamaram da falta de sete pães. Estava no piso superior, podendo ver abaixo pois é aberto. Indagou aos presos do raio 2 se havia sobra, e eles responderam que sim. Foi autorizada a transferência de alimento ao raio 3 pelo preso responsável. Os raios ficam um de frente para o outro. O réu disse que estava com os pães e pediu para adentrar na gaiola. O portão do raio 2 foi aberto. O acusado não era preso encarregado do trabalho com as refeições, o que lhe chamou a atenção. Há indicação de presos determinados para cada atividade. Fechou o portão do raio 2. O acusado ficou dentro da gaiola, demonstrou inquietação, olhando para os raios constantemente e para ele, agente Jefferson. Percebeu que poderia haver algo errado e pediu para o agente Emerson abrir o portão. A abertura dos portões é lenta, por ser feita de forma eletrônica. Escutou o acusado virar e dizer: "olha o guarda !". Um outro preso do raio 3 falou: "Passa ! Passa !". Quando o portão estava abrindo, viu que o réu passou algo pela abertura, com aparência de tratar-se de chips de celular. A abertura é de 2 cm e serve para entrega de documentos. Quando o portão abriu, entrou na gaiola e o abordou. Com ele, havia ainda uma caixinha de fio dental. O acusado foi conduzido para a sala de revista. Em princípio, ele relutou em atender o comando. Depois, na presença de dois funcionários, acabou indo para a sala. Na caixa de fio dental, foram encontrados dois quadradinhos de "K-4". Não foi possível apreender os itens que o réu passou para o outro lado antes da abordagem. Como não havia materialidade a respeito de tais itens, não os mencionou no comunicado de evento. O réu iria passar a caixa de fio dental junto com os pães. Tanto a caixa como os pães estavam nas mãos dele. Ele tentava entregá-los no raio 3. O acusado não deu justificativa. Pelo que se recorda, não foi realizada vistoria no raio 3 para tentar encontrar os chips de celular pois a unidade tem mais de dois mil e seiscentos presos, com cerca de mil presos por pavilhão. Há revista regular nas celas. A porta tem uma abertura de 2 cm, destinada a passar documentos, como procuração, para o reeducando assinar. A abertura em questão situa-se abaixo de uma pequena tela. Acredita que tenham sido passados chips de celular pelo acusado. Somente estava ele na gaiola, espaço que possui cerca de três metros e meio por três metros, bem como quatro portas. Uma fica de frente para outra, no alojamento. É um retângulo, sendo que cada lado tem uma porta. As duas portas do raio tem o vão mencionado. As outras duas possuem espécie de grade. Quando viu o ocorrido, estava em cima, sendo que o segundo andar é vazado. DO segundo andar, tem-se plena visão do andar de baixo. Presume que ele não contava que fosse visto. O acusado conseguia ver o agente em cima. Teve que descer por uma escada para chegar até onde o réu estava. Todos os quatro portões

eram acionados eletronicamente. Após o ocorrido, foi colocado acionamento manual para que o agente possa chegar mais rápido. Em razão do portão automático, chegou segundos depois, tendo havido tempo de o acusado passar itens que presume ser chips de celular.

A testemunha Emerson Florencio Barbosa, também agente de segurança penitenciária, disse que prestava serviços na gaiola 2, a qual possui dois pavimentos. Os agentes ficam no de cima. Foi dada falta de pães em um dos raios. O réu entrou para entregar os pães excedentes ao outro raio. Quando ele adentrou na gaiola, o outro agente percebeu uma atitude diferente por parte do acusado. Ele passou algo pela tela e tentou passar outro objeto. O agente Jefferson desceu e deu ordem de parada. Desceu em seguida. Durante a abordagem, foi apreendida caixinha de fio dental contendo possivelmente "K-4". As portas de acesso aos raios ficam dentro na gaiola, na parte de baixo. Os agentes controlam a abertura das portas automáticas de cima, de onde podem ver o andar de baixo, pois a separação entre os pavimentos é vazada. Na ocasião, eram quatro portas. Uma do raio 3, outra do 2, a terceira dos fundos e a quarta da galeria. Foi aberta a porta do raio 2 e depois fechada, para o réu passar os pães para o raio 3. A gaiola fica no final da galeria. Nessa passagem de um raio ao outro, o réu passou algo para o outro lado por meio da tela de cerca de 2 cm, mas ficou com um fio dental nas mãos, objeto este que ele não conseguiu entregar. Talvez ele o passaria quando os agentes abrissem a porta do raio 3 para entregar os pães. Depois que o acusado entrou na gaiola, a porta do raio 2 foi fechada, e seria aberta a porta do raio 3 para ele passar os pães. Como os agentes perceberam a conduta do réu, não abriram a porta e ele não conseguiu passar a caixa, pois a dimensão dela é maior e não passava na fresta da tela. Se os agentes tivessem aberto a porta, o acusado teria passado a caixa junto com os pães. As portas têm acionamento automático e são controladas da parte de cima da gaiola. Somente é aberta uma porta por vez, por razões de segurança. Os agentes ficam bem em cima dos presos e podem abrir e fechar as portas a cerca de dois metros dos presos. Estava junto com Jefferson na parte de cima. Antes que o réu passasse algo para o raio 3, não ouviu conversa entre ele e outro preso. São 900 presos em cada raio e há muito barulho. Estavam em dois agentes no plantão. Nunca havia recebido informação prévia a respeito do envolvimento do acusado com crimes no presídio. A escolha dos presos para determinadas atividades é passada pelo agente responsável pelo trabalho, o qual repassa para o Diretor de Disciplina. Se os dois estiverem de acordo, o preso é designado. Há registro disso na unidade prisional. Não se lembra se o acusado era designado para alguma atividade.

Interrogado em juízo, o réu afirmou que o fato se passou no domingo. A tranca abriu às seis horas da manhã. Saiu para entregar o café com outros detentos. Sempre os ajudava. Após o término das entregas, os presos do raio 3 informaram que havia faltado pães. Pediu-lhes que esperassem a entrega no raio 2. Após, constatou que sobraram seis pães para os presos ali custodiados. Informou que mandaria sete pães para o raio 3. O agente foi informado e autorizou a transferência dos pães entre os raios. Pegou sete pães com as mãos para entregar no raio 3. O agente abriu a gaiola e, em seguida, falou para esperar e que desceria. Quando ele se aproximou, perguntou o que havia entregue aos meninos. Respondeu que nada havia para entregar, pois somente estava com pães. O agente novamente o indagou, dessa vez perguntando se havia entregado chips. Insistiu que somente tinha pães em suas mãos. O agente abriu a porta de trás e o chamou para entrar, pedindo para revistá-lo. Colocou os pães numa mesa. O agente perguntou o que tinha nos bolsos. Explicou-lhe que trazia uma tesoura e a entregou. O agente novamente indagou o que havia entregue. Outra vez lhe disse que somente tinha pães, sendo três numa mão e quatro na outra. O funcionário lhe disse que ficaria dez dias no castigo e que, no período, iria ver o que faria com ele. Relatou-lhe que estava com seu "R A" pronto e que a "saidinha" estava próxima. Mesmo assim, o agente o mandou para o castigo. Não portava caixa de fio dental, mas apenas pães e a tesoura.

Diante de tal conjunto probatório, impõe-se a condenação do acusado nos termos da denúncia, não merecendo guarida as teses expostas nas alegações finais produzidas em sua defesa.

É certo que o réu, quando interrogado em juízo, negou a prática do tráfico.

A negativa, no entanto, soa como forma natural de afastar a responsabilidade criminal e suas consequências, e não pode ser admitida, porque em contradição com a lógica e com a prova produzida.

Isto porque o crime de tráfico foi comprovado pelo depoimentos de dois agentes de segurança penitenciários, que flagraram o réu portando a caixa de fio dental contendo o entorpecente e tentando entregá-la a terceiros.

As afirmações dos agentes se afiguram firmes, coerentes e comedidas ou sem tendências para o exagero, merecendo, por isso, serem tidas como expressão da verdade.

De resto, a jurisprudência já assentou a validade da prova consistente em depoimentos de agentes públicos encarregados da manutenção da ordem.

À propósito:

"Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunha a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecente por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição." (RT 610/369).

Em igual sentido:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-la pelo só fato de emanar de agentes estatais, incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal." (STF, D.J. 18/10/96, Habeas Corpus n. 73.518-5 São Paulo, rel. Min. Celso de Mello).

E, especificamente em relação a depoimentos de agentes de segurança penitenciária:

"(...) o reconhecimento da prática de falta grave baseou-se especialmente nos depoimentos de dois agentes penitenciários que gozam de fé pública -, os quais narraram de forma uníssona e harmônica a utilização, pelo paciente, de telefone celular em unidade prisional. Por isso, a ausência de apreensão do aparelho, por si só, não pode afastar tal conclusão." (HC 254.312/Sp, rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 06/08/2013, DJE 13/08/2013). (em TJSP, Apelação n. 0029345-41.2013.8.26.0071, rel. Silmar Fernandes, j. 13/11/2015).

Assim, o fato descrito na denúncia e respectiva autoria estão bem demonstrados.

Por outro lado, não paira dúvida de que a droga tinha a destinação de tráfico e não de consumo pessoal pelo réu.

Afinal, o agente de segurança penitenciária Jefferson disse ter notado que, pouco antes da abordagem, o acusado teve tempo de passar algo a um outro preso do raio 3, não tendo sido possível a apreensão dos itens entregues, aparentemente chips de celulares.

Logo, a partir de tal circunstância, extrai-se a ilação de que o acusado, valendo-se da chance de estar em contato com presos do raio 3 para fazer a entrega de alguns pães, aproveitou-se para também repassar itens ilícitos, não somente provavelmente chips de telefonia, como também a droga.

Tal conclusão ganha força na medida em que, se mero usuário fosse, o réu não traria as porções de entorpecente consigo ao se posicionar na gaiola da unidade, entre os raios 2 e 3 do presídio, à vista dos agentes Jefferson e Emerson, pois muito mais seguro e menos arriscado teria sido que as guardasse em meio a seus pertences na sua própria cela, onde inexistia a mesma vigilância direta.

Por outras palavras, o acusado somente carregava a droga para poder entregá-la a outro preso de raio diverso daquele em que habitava, já que o momento lhe permitiu oportunidade para tanto.

De resto, cabe observar que o art. 33, caput, da Lei Antidrogas define crime de conteúdo múltiplo e de perigo abstrato.

Dessa forma, basta que o agente incorra em qualquer dos verbos ali descritos, desde que sem a finalidade de consumo da droga, para que o delito de tráfico reste caracterizado.

Não é indispensável, assim, que o agente seja flagrado em pleno ato de mercancia de droga, sendo suficiente que a traga consigo (conforme descrito na denúncia e comprovado na instrução).

Destarte, não há como absolver, e nem mesmo como desclassificar a conduta para a prevista no art. 28 da Lei Antidrogas.

Não há que se cogitar de afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, apenas em razão do fato de o autor do delito ser detento, pois a lei não faz distinção.

Nesse sentido:

"De igual modo, é caso de manter o aumento decorrente do fato de ter sido praticado o delito nas dependências de estabelecimento prisional, incidindo, na espécie, a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006.

Ressalte-se que referida majorante não deixa de incidir quando o agente é detento do presídio, porquanto a lei não traz qualquer particularização a respeito da característica do autor do crime. O colendo Superior Tribunal de Justiça já havia assentado entendimento de que a causa de aumento prevista no inciso IV do artigo 18 da antiga Lei n. 6.368/76 era aplicável ao presidiário que comete o crime de tráfico de entorpecentes nas dependências do estabelecimento penal: 'Para incidência da causa de aumento prevista no artigo 18, inciso IV, da Lei n. 6.368/76, in casu, delito cometido dentro do estabelecimento penal, pouco importa que o crime tenha sido praticado por agente que esteja em liberdade ou por preso. (Precedentes do Pretório Excelso e do STJ)'. (REsp 662779/MG; Recurso Especial 2004/0078379-7, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma)." (em TJSP, Apelação n. 0000339-05.2010.8.26.0326, Rel. Borges Pereira, j. 04/12/2012).

Em suma, deve o réu ser condenado nos termos da denúncia.

Passa-se à aplicação da pena.

Fixa-se a pena base no mínimo legal, ou seja, cinco anos de reclusão, mais quinhentos dias-multa.

Desconsidera-se a certidão de fls. 100/101 - art. 157, §2º, incisos I e II, Código Penal - enquanto demonstrativa de antecedente criminal, pois nela não há menção ao trânsito em julgado para a defesa.

O réu é reincidente (fls. 100 - art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, e artigo 244-A, ECA).

Diante disso, eleva-se a pena na proporção de um sexto, resultando em cinco anos e dez meses de reclusão, mais quinhentos e oitenta e três dias-multa.

Presente a causa de aumento de pena do art. 40, inciso III da Lei 11.343/06, eleva-se a pena na proporção de mais um sexto, resultando em seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, mais seiscentos e oitenta dias-multa.

Não havendo outras modificadoras, tais penas são as definitivas.

Ante o montante da pena aplicada e a reincidência, o regime inicial de cumprimento de pena será o fechado.

O valor do dia-multa será calculado no piso mínimo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, para condenar o réu Matheus Adriano Tauhyl Machado como incurso nas penas do artigo 33, caput, combinado com art. 40, inciso III da Lei n. 11.343/2006, a cumprir seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar seiscentos e oitenta dias-multa, calculado o valor do dia-multa no piso mínimo.

Oportunamente, anote-se a condenação no sistema informatizado.

P.R.I.

Bauru, 09 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA